

刑事缺席审判程序被告人权利的演进 逻辑与规范阐释

自正法 吴万强 *

内容摘要 2018 年修改的《刑事诉讼法》规定新增刑事缺席审判程序，其主要目的是打击贪污腐败分子，完善追逃追赃机制。作为一项新增制度，缺席审判程序的立法进程经历了激烈的争论，也引发关于该程序是否有违正当程序的质疑。对此，缺席审判程序设置了严格的适用情形，并**从程序上和实体上**对被告人的权利加以保障。但缺席审判程序的法条表述较为笼统，首次施行也没有以往经验可用以参考，缺席审判程序在具体适用时仍有可能侵害被告人的权利，如**误伤非恶意缺席被告人，减损被告人知情权、辩护权、上诉权和财产救济权等**。为了修正这些弊端，我们应当明确仅对潜逃境外的被告人启动缺席审判，确保缺席被告人获得“有效辩护”，在程序上保证被告人实际知情权并明确上诉权行使顺位，在实体上完善财产救济机制，以期有效保障被告人的程序性和实体性权利，**发挥缺席审判程序既惩罚犯罪，又保障被告人人权之目的。**

关键词 刑事缺席审判 正当程序 有效辩护 实体性权利 程序性权利

一、问题的提出

为了进一步打击腐败分子，推动反腐追赃工作，2018 年 10 月 26 日，全国人大

* 自正法，重庆大学法学院副教授、博士生导师；吴万强，香港城市大学法学硕士。
本文为中央高校基本业务科研创新能力提升专项课题“互联网法院运行逻辑的理论基础与完善路径研究”（2018CDJSK08YJ07）、司法部国家法治与法学理论研究课题“有限责任公司股东压制问题研究”（16SFB3028）的阶段性成果。

常委会审议通过《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》(以下简称《刑事诉讼法》),决定在第五编特别程序中新增缺席审判程序作为第三章,从而构建起中国特色的刑事缺席审判制度。整个缺席审判程序由《刑事诉讼法》第291条至297条共7个条文组成,主要规定了针对贪污贿赂犯罪案件的适用情形、管辖送达,以及缺席被告人的辩护权、上诉权和异议权等内容。^[1]

虽然中国境外追逃追赃实践经验丰富,^[2]在法律规范层面也有实施“违法所得没收程序”七年的经验积累,可以说在平衡打击犯罪与保障人权方面,我国司法机关已经拥有一套较为成熟的做法,但缺席审判程序毕竟打破了传统刑事诉讼的“三角结构”,限制了缺席被告人的基本权利,因此学界正对该程序是否有违正当程序进行激烈的争论。例如,有学者认为缺席审判程序是“有天然缺陷的制度”,^[3]也有学者认为新增的缺席审判程序明显背离正当法理。^[4]为了补强缺席审判程序的正当性,必须严格保障缺席被告人的基本权利。但由于缺席审判程序仅有的7条规定过于笼统模糊,无法充分保障被告人的基本权利,而且学界研究还大多围绕缺席审判程序的基本内容,立法技术与合理性等方面,^[5]对具体权利保障措施的研究尚未全面展开。^[6]因此,本文旨在解决缺席审判程序被告人权利保障问题,着眼于被告人的基本权利,一方面从规范维度揭示刑事缺席审判程序被告人权利保障的演进逻辑;另一方面从程序性和实体性权利保障维度,在现行法律框架下分析缺席被告人面临的潜在风险,在此之上

[1] 缺席审判程序的7个条文还规定了其他四种情形:(一)犯罪嫌疑人、被告人在境外,需要及时进行审判,经最高人民检察院核准的严重的危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件(《刑事诉讼法》第291条);(二)由于被告人患有严重疾病,无法出庭的原因中止审理超过六个月,被告人仍无法出庭,被告人及其近亲属、法定代表人申请或同意恢复审理的案件(《刑事诉讼法》第296条);(三)被告人死亡但有证据证明被告人无罪的案件(《刑事诉讼法》第297条第1款);(四)人民法院按照审判监督程序重新审判的被告人死亡的案件(《刑事诉讼法》第297条第2款)。本文主要论述贪污贿赂案件中缺席被告人的权利保障,因此对于以上四种情形暂不讨论。

[2] 我国拥有一套多元化的追逃追赃渠道,例如搭建国际合作框架,加强国际刑事司法合作,发布“红色通缉令”等。

[3] 王敏远:《刑事缺席审判制度探讨》,载《法学杂志》2018年第8期。

[4] 左卫民:《如何打造具有法理合理性的刑事诉讼法——审思2018年刑事诉讼法修正案》,载《比较法研究》2019年第3期。

[5] 重点研究缺席审判程序基本内容、立法技术与合理性的代表性论著有:陈卫东:《论中国特色刑事缺席审判制度》,载《中国刑事法杂志》2018年第3期;袁义康:《刑事缺席审判程序的合理性及其完善》,载《华东政法大学学报》2019年第2期;万毅:《刑事缺席审判制度立法技术三题——以中华人民共和国刑事诉讼法(修正草案)为中心》,载《中国刑事法杂志》2018年第3期;樊崇义:《刑事诉讼法修改的重点难点问题解读》,载《法律适用》第2019年第3期;喻海松:《刑事缺席审判程序的立法进程》,载《法律适用》2018年第23期等。

[6] 论述研究缺席审判程序被告人权利保障的论著主要有:杨雄:《对外逃贪官的缺席审判研究》,载《中国刑事法杂志》2019年第1期;张澎、姜金良:《论刑事缺席审判制度的具体构建——以刑事诉讼法(修正案)为基础》,载《中国社会科学院研究生院学报》2018年第6期。

凝练和挖掘缺席审判被告人的权利保障路径,以期进一步细化和落实刑事缺席审判程序。

二、缺席审判程序被告人权利演进的逻辑结构

《刑事诉讼法》新增缺席审判程序,满足了惩治腐败的现实需要,也符合法院创新审理模式的改革趋势。但该程序的出台并非“一帆风顺”,其间经历了三次研拟讨论,争议焦点集中在缺席审判程序适用的范围和被告人权利保障的程度。

(一) 缺席审判程序被告人权利演进的背景

1. 惩治腐败进入新阶段

党的十八大以来,中央在深化国家监察体制改革,加强反腐败追逃追赃等方面取得阶段性佳绩,但正如习近平总书记在党的十九大报告中所言:“只有以反腐败永远在路上的坚韧和执着,深化标本兼治,保证干部清正、政府清廉、政治清明,才能跳出历史周期率,确保党和国家长治久安。”^{〔7〕}国际追逃、追赃是我国反腐败工作的重要内容,其主要项目是抓捕“红色通缉令”名单中的百名腐败分子。据新华社消息,截至2019年5月28日,中国“红色通缉令”名单中的57人已经归案,但仍有43名腐败分子逍遥法外,当前国际追逃、追赃任务依然复杂艰巨。在规范层面上,要推进国际追逃、追赃工作,必须解决两大制度难题:一是违法所得没收程序打击力度不足,二是我国加入的《联合国反腐败公约》规定国际追赃原则上需要出示生效判决。^{〔8〕}

一方面,违法所得没收程序的处理范围仅限于涉案财物。在2012年《刑事诉讼法》确立了违法所得没收程序,即允许法院对通缉一年仍不能到案的犯罪嫌疑人、被告人依法追缴其违法所得及其他涉案财产。该程序一定程度上解决了海外追赃问题,但不论是刑事诉讼目的或反腐目的,皆为将腐败犯罪分子缉拿归案、绳之以法,使之受到法律的制裁,而不仅仅是对涉案财物予以没收。换言之,刑事诉讼以追究罪犯人身刑罚为主要目的,单纯的财物没收难以完全发挥刑事诉讼打击腐败,威慑犯罪的作用。

另一方面,请求国请求被请求国返还本国贪官携带过去的巨额财产时,必须提供生效的判决文书。虽然《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)也规定被请求国

〔7〕 习近平:《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,人民出版社2017年版,第67页。

〔8〕 《联合国反腐败公约》第57条第3款第二项规定:对于本公约所涵盖的其他任何犯罪的所得,被请求缔约国应当在依照本公约第55条实行没收后,基于请求缔约国的生效判决,在请求缔约国向被请求缔约国合理证明其原对没收的财产拥有所有权时,或者当被请求缔约国承认请求缔约国受到的损害是返还所没收财产的依据时,将没收的财产返还请求缔约国,被请求缔约国也可以放弃对生效判决的要求。

可以主动放弃对生效判决的要求,但在涉外司法实践中,我国几乎从未享受这一“待遇”。因为目前我国外逃的腐败分子大多藏匿于美国、加拿大和澳大利亚,这些西方国家由于意识形态和司法制度与我国相异,在司法协助实践中常常坚持要求生效的司法判决。仅提供一份经违法所得没收程序作出的裁定文书,难以说服西方国家的司法机构协助我国海外追逃、追赃,客观上也给了腐败分子逃避惩治的可乘之机。

目前,解决这两大制度难题的时机已经成熟,为了推动我国反腐败工作进入新阶段,继续加强国际追逃、追赃力度,全国人大常委会通过了《刑事诉讼法(修正案)》,决定新增刑事缺席审判制度。

2. 法院创新审理模式与有限资源的优化配置

最高人民法院一直将“创新审判模式,提高诉讼效率”作为一个阶段性工作重点。2016年9月最高人民法院印发的《关于全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的实施意见》专章指出:“完善繁简分流机制,优化司法资源配置”。

这一审判模式的创新在提高诉讼效率方面固然成效显著,但只要一个案件进入诉讼程序,无论适用多么简单的审理程序,一旦中止就必然导致诉讼周期延长和司法资源重复投入,^[9]让早已捉襟见肘的司法资源更加难以承受,严重降低诉讼效率。例如,在普通的刑事案件中,若被告人缺席,法院一般会中止审理,但中止并不等于纠纷解决,犯罪认定和民事赔偿等问题仍然需要法院作出判决。不问理由一味地中止审理会造成案件积压,而积压的案件又需要持续地投入司法资源进行管理,直到缺席被告人重新到案,再继续或者重复原来的诉讼程序。这极大地降低了诉讼效率,也不利于司法公正。诚如张文显教授所言:“一个社会无论多么公正,如果没有效益,必将导致社会的集体贫穷,那也谈不上什么公正,即使有这种公正也是社会和人民所不取的。”^[10]

刑事缺席审判程序能在客观上避免因被告人缺席而导致诉讼中止的情形,从而提高诉讼效率,助推司法公正。虽然目前《刑事诉讼法》将缺席审判的适用局限于五种法定情形,但在《刑事诉讼法(修正案)》第二次审议时有意见提出:“先将缺席审判程序案件适用范围明确,待《刑事诉讼法(修正案)》施行后再行通过司法解释予以扩大。”^[11]全国人大常委会法工委主任沈春耀也表示:“建立刑事缺席审判制度是从反腐败追逃追赃角度提出的,但不仅限于贪污贿赂案件,其他重大案件确有必要及时追究的,在充分保障诉讼权利的前提下,也可以进行缺席审判。”^[12]这些意见都暗示

[9] 肖沛权:《价值平衡下刑事缺席审判制度的适用》,载《法学杂志》2018第8期。

[10] 张文显:《法学基本范畴研究》,中国政法大学出版社1993年版,第273页。

[11] 前引〔5〕,喻海松文。

[12] 参见全国人大常委会法制工作委员会:《关于〈中华人民共和国刑事诉讼法(修正草案)〉的说明》,中国人大网, http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/2018-04/26/content_2053717.htm, 2019年3月1日访问。

现行的缺席审判程序可作为一个先行试点,如果运行得当,未来有可能通过司法解释将刑事缺席审判程序扩大适用于其他类型的案件,从而全面提高诉讼效率,进一步创新法院审理模式,实现有效司法资源的最优配置。

(二) 缺席审判被告人权利保障的立法进程

1. 立法进程:适用范围的变更

缺席审判程序的适用范围看似与被告人的具体权利关系不大,但其范围大小直接决定哪些人可能成为被告人。一个缜密精准的适用范围是切实保障公民权利的基础,因此这一问题是本次审议过程中争论最为激烈的部分。

在草案第一次审议研拟过程中,与会专家的共识是,缺席审判主要适用于贪污腐败案件。但分歧在于,刑事缺席审判程序是否应明确仅适用于“贪腐案件”,有无扩大适用可能?一审稿的意见是:“对于贪污贿赂等犯罪案件,检察院可以向人民法院提起公诉。”该意见引发了激烈讨论,一方面,有人认为设立刑事缺席审判程序的主要目的是打击腐败,追逃追赃,因此可以删去一审稿中“贪污贿赂等犯罪案件”中的“等”字,从而避免司法实践中出现扩大解释,滥用这一尚未成熟的新制度;另一方面,也有意见认为刑事缺席审判程序在国外运用成熟而且成效显著,如果未来条件允许且确有必要,可以将缺席审判程序扩大适用于贪污贿赂犯罪以外的案件。因此他们认为有必要保留“等”字,毕竟通过司法解释扩大适用范围比重新立法更具现实可能性。

经过宪法和法律委员会、法制工作委员会的认真研究,二审稿认为:刑事缺席审判程序的确从反腐角度提出,但缺席审判作为一种行之有效的审理模式,不可局限于“贪腐案件”,其他重大案件确有必要时也可以适用缺席审判。但目前该制度确实可能存在因经验不足,立法模糊而滥用程序的情况,因此二审稿将缺席审判案件范围更加明确地规定为“贪污贿赂犯罪案件,以及需要及时进行审判,经最高人民检察院核准的严重的危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件”。这一规定表面上扩大了缺席审判程序的适用范围,但实际上将缺席审判的适用明确限定于这两种案件类型之中,缩小打击面,保障公民合法权利。这一观点最终为《刑事诉讼法修改决定》所沿用,后仅作表述微调。^[13]

2. 立法进程:聚焦缺席被告人权利保障

刑事缺席审判程序天然地克减了被告人的诉讼权利,设计一套合理的权利保障机制是该程序通过审议的关键。因此,一审稿明确要充分保障缺席被告人的诉讼权利:一是保障其“辩护权”,即“被告人有权委托辩护人,被告人的近亲属可以代为委托辩护人。被告人及其近亲属没有委托辩护人的,人民法院应当通知法律援助机构

[13]《刑事诉讼法修改决定》表述为“对于贪污贿赂犯罪案件,以及需要及时进行审判,经最高人民检察院核准的严重危害国家安全犯罪恐怖活动犯罪案件”。

指派律师为其提供辩护”。二是保障其“上诉权”，即“人民法院应当将判决书送达被告人及其近亲属、辩护人。被告人或者其近亲属不服判决的，有权向上一级人民法院上诉。辩护人经被告人或者其近亲属同意，可以提出上诉”。三是保障其“异议权”，即“罪犯在判决、裁定发生法律效力后归案的，人民法院应当将罪犯交付执行刑罚。交付执行刑罚前，人民法院应当告知罪犯有权对判决、裁定提出异议。罪犯对判决、裁定提出异议的，人民法院应当重新审理”。

审议各方认为保障被告人以上三种权利确有必要，但缺席被告人异议权行使条件以及是否将缺席审判案件纳入法律援助，立法过程中各方分歧极大。

一方面，被告人在审理结束归案后行使异议权，法院是否一律重新审理？反对意见认为应当对被告人异议权加以限制，例如，要求被告提出异议线索，理由有三点：一是为了维护生效判决的既判力，毕竟缺席判决同样是经过合法程序作出的有效判决，无条件的异议权会损害司法权威；二是为了节约司法资源，因为无条件的异议权客观上给了被告人滥用权利、拖延诉讼的机会；三是为了维护整体司法公正，因为缺席被告人享有异议特权即意味着对其他案件被告人不公。而支持缺席被告人享有无条件异议权的意见认为：新增缺席审判程序的主要目的是打击腐败，即通过生效判决获得被请求国的司法协助，从而引渡腐败分子回国受审。为了实现这一目的，根据国际惯例以及我国《引渡法》的规定，^[14]必须保障缺席被告人归案后获得无条件重新审判的机会。二审稿和《刑事诉讼法修改决定》采纳了这一观点，并且沿用一审稿的表述。

另一方面，是否将缺席审判案件纳入法律援助范围，各方意见不统一。例如，有常委会委员认为：“涉及追逃追赃的刑事被追诉人，不是没有能力请律师辩护，而是为了逃避管辖，出于社会公平的考量，无论如何都不应是法律援助的对象。”^[15]还有意见认为，缺席审判程序与违法所得没收程序有一定相似性，后者也没有纳入法律援助范围。而且，即使为缺席被告人指定辩护律师，无法与被告人充分沟通的辩护律师，在案件审理中所起的作用也不大。因此有审议意见建议删除一审稿中法院为缺席被告人指定援助律师的规定。但为了充分保障被告人辩护权，二审稿并未采纳上述意见，仍然坚持将缺席审判案件纳入法律援助范围。

三、缺席审判程序被告人权利保障的诠释与潜在风险

缺席审判中被告人不在案，许多权利被迫克减，因此立法者在程序上和实体上

[14] 国际惯例是“对于根据缺席审判的有罪判决提出的引渡请求，许多国家都要求请求方作出承诺：在引渡后对被引渡人重新进行审判”；我国《引渡法》第8条第8款同样规定：只有当“请求国承诺在引渡后对被请求引渡人给予在其出庭情况下重新审判机会”时，才考虑引渡。

[15] 朱宁宁：《常委委员分组审议刑法修正草案时建议通盘研究刑事缺席审判制度》，载《法制日报》2018年4月28日第2版。

对被告人权利进行补强,以期强化缺席审判程序的正当性。但当我们细细解读法条,仍能从中发现许多潜在的风险。立法及司法解释并未对被指控人的程序性权利和实体性权利进行类型化规定,而是依据权利内容进行列举分散式规定,其中所谓程序性权利指主体为行使其实体性权利而必须具有的作一定行为的能力,包括知情权、辩护权、上诉权等;实体性权利指人们对某种实体利益所具有的受法律保护资格和权能,包括生命权、自由权和财产权等。而被告人的异议权既涉及对人身权利的救济,又涉及对财产权的直接保护,因此同时具有程序性权利和实体性权利的属性。在此,本文将异议权涉及人身权的部分划分为程序性权利,涉及财产权救济的部分划分为实体性权利。

(一) 刑事缺席审判程序被告人权利的解读

1. 缺席审判程序的适用情形

为了保障犯罪嫌疑人、被告人的合法权利不受侵害,缺席审判程序设置了严格的适用情形,避免出现滥用缺席审判的情况。作为一项专门针对在境外的贪污腐败分子的审判程序,具体设计包括管辖、起诉、审判和送达等内容,由《刑事诉讼法》第291条规定。

缺席审判案件由人民检察院审查起诉,同普通刑事案件一样,启动缺席审判的前提依然是“犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任”。案件由犯罪地、被告人离境前居住地或者最高人民法院指定的中级人民法院管辖,且需组成合议庭审理。该规定遵循了一般地域管辖原则,主要为方便收集证据,尽快恢复当地被破坏的社会秩序,但由于贪污贿赂案件往往具有重大性、复杂性和敏感性,为了减少办案阻力,保证司法机关独立办案,此类案件也可由最高人民法院指定管辖。级别管辖设计是出于对此类案件涉外性的考虑,因为中级人民法院有足够的权限与国外司法机构对接,方便启动送达程序。此外,考虑到此类案件专业性较强,复杂度较高,已经不适合由独任法官或陪审员处理,因此规定审判庭由专业的审判员组成合议庭进行审理。

2. 缺席审判程序被告人享有的程序性权利

为了符合程序正义的要求,也为了能够保护和实现法律赋予公民的实体权利,缺席审判设置了严密的程序限制,以期保障被告人的程序性权利。首先,缺席被告人享有程序知情权,又称被告知的权利(the right to be informed),即刑事诉讼中被告人有权知悉与其利益攸关的事实及决定的权利,这也是被告人作为程序主体参与诉讼和有效辩护的一个重要条件。^[16]《刑事诉讼法》第292条规定了缺席被告人的知情权,并通过送达程序落实。送达程序的目标是通过各种途径确保缺席被告人实际知晓,这也是缺席审判的正当性基础。具体而言,人民法院将通过国际条约规定的或外交途径提出的司法协助,或者通过被告人所在地法律允许的其他方式,将传票和起诉书副本送达被告人。此外,为了充分保障被告人的知情权,《刑事诉讼法》第294条还规定

[16] 肖晋:《刑事被指控人程序性权利研究》,载《河北法学》2009年第7期。

法院应当将判决书送达被告人的近亲属和辩护人,因为他们之间很可能存在联系,以期间接通知被告人。

其次,缺席被告人享有辩护权,这是被告人最重要的程序性权利,保障缺席被告人辩护权是缺席判决获得被请求国承认的关键。因此《刑事诉讼法》第293条规定,被告人有权委托辩护人,被告人的近亲属也可以代为委托辩护人,法院还把此类案件纳入法律援助范围,即被告人及其近亲属都没有委托辩护人时,法院会依职权指派律师为被告人辩护。

再次,缺席被告人享有上诉权,无上诉则无权利,上诉权也是被告人重要的程序性权利之一,缺席审判通过赋予被告人上诉权来保障其救济权利。根据《刑事诉讼法》第294条,缺席审判中的上诉权不仅被告人享有,其近亲属也同样独立享有,辩护人在经过被告人或其近亲属同意后也可以提出上诉。

最后,缺席被告人享有涉及人身部分的异议权。《刑事诉讼法》第295条赋予了被告人异议权,即被告人到案后,交付执行刑罚前可以对判决、裁定提出异议,此时法院应当重新审理,而且是无条件重新审理。有些学者认为应当对被告人的异议权做出一定的限制,比如规定被告人提交新的证据或线索才能行使异议权,因为完全的异议权极有可能被滥用,从而降低司法效率。^[17]但全国人大法工委沈春耀主任已经明确说明,刑事缺席审判程序主要是为追讨贪官,即该制度的主要目的是通过缺席判决获得国外司法协助,将腐败分子缉拿归案,所以司法效率并不是此项制度的主要追求目标。再根据上文所述的国际引渡惯例和我国《引渡法》的规定,可以看出,坚持赋予被告人无条件异议权是获得国外司法机关承认与协助的前提,我国与法国、澳大利亚、西班牙、葡萄牙等国家之间签订的引渡条约也都有类似规定。因此对于缺席被告人异议权的行使,无论如何都不应设置条件。此外,为了让被告人无顾忌地行使异议权,重新审理的结果不应当重于原判决。法律还规定,如果审理过程中被告人到案,无论是自动投案还是被动抓获,人民法院都应当重新审理,因为此时缺席审判的基础已经丧失。

3. 缺席审判程序被告人享有的实体性权利

财产权作为被告人重要的实体性权利,在着重保障被告人程序性权利的缺席审判中同样受到重视。近代以来,无论是自然法思想宣扬的“私人财产神圣不可侵犯”,还是《法国人权宣言》首次将财产权写入宪法的做法,均表明财产权是与人身权同等重要的宪法性权利。因为公民的生存与自由需要一定的物质基础作为前提,个人财产不受保障,则个人的物理生存面临危机,更谈不上精神上的独立和尊严。^[18]因此我国《宪法》第13条第2款规定:“国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。”同样,为了延续宪法保障私有财产的理念,《刑事诉讼法》第295条第3款规定:“若依照生效判决、裁定对罪犯的财产进行的处理确有错误的,应当予以返还、赔偿。”

[17]前引〔5〕,陈卫东文。

[18]谢立斌:《论宪法财产权的保护范围》,载《中国法学》2014年第4期。

值得一提的是,缺席审判程序对被告人财产权的保障根源于违法所得没收程序,甚至连财产权救济条文都采用相同表述。^{〔19〕}据此可以推定,在司法实践中,缺席审判程序对被告人财产的处理必然会参考违法所得没收程序。然而,在违法所得没收程序实施的7年里,虽然该程序为国家追回了大量赃款、赃物,但也一直存在着巨大的可能危及到公民合法财产的风险。缺席审判程序作为违法所得没收程序的“升级版”,应当进一步完善财产权的保障和救济措施。

(二) 缺席审判程序被告人权利的潜在风险

缺席审判程序作为一项刑事特别程序,整体设计思路清晰,针对性强,也相当重视被告人的权利保障,但现行法律文本显然未能充分意识到被告人缺席所带来的对抗失衡的严重性,表述笼统的法条也未能充分保障被告人权利,因此缺席审判程序可能侵害被告人的合法性权利。

1. 非恶意缺席被告人或被误伤

缺席审判程序的适用前提是贪污贿赂案件被告人身处境外,这一表述只描绘了被告人的客观状态却未考虑其主观动机,即是说只要被告人身处境外,一概可以对其进行缺席审判。但身处境外可以是主观原因,比如畏罪潜逃,也可能因为客观原因,比如下落不明或滞留境外,我们将此类缺席被告人称为“非恶意缺席”被告人。不加区分地对被告人适用缺席审判程序可能扩大打击范围,“误伤”“非恶意缺席”的被告人。

虽然现代刑事诉讼理论允许缺席审判,但由于刑事诉讼案件往往关系重大,公诉机关地位强势,国际上普遍要求尽可能保障被告人的出庭权。这种做法并非要避免“缺席审判”,而是要尽可能避免“不公正的缺席”。^{〔20〕}例如,联合国《公民权利和政治权利国际公约》第14条第3款将被告人“出席受审并亲自或经由他所选择的法律援助进行辩护”规定为“在判定对他提出的任何刑事指控时,人人完全平等地有资格享有的”最低限度的权利保障,可见尊重当事人出庭权是刑事缺席审判程序的正当性基础。虽然《欧洲人权公约》并未明确规定被告人的出庭权,但规定了被告人辩护权和对质权等基本权利,^{〔21〕}而出庭权是行使这些权利的前提,又因为各成员国须尽力保障被告人基本权利,因此也需要保障被告人出庭权,除非被告人主动放弃,由此才能进行缺席审判。

具体到司法实践中,被告人通常不会明确向法庭表示“自愿放弃出庭权”,因此法庭只能依据被告人的行为进行推断。如果被告人为逃避刑事责任而潜逃,故意隐匿身份、地址等信息让相关文书无法送达,那么法庭就能够推断其已经知晓将要到来的审判,也就能够启动缺席审判程序。但如果被告人属于下落不明或滞留境外等非故意逃避司法审判的情况,那么法庭应当延期或中止审理,而非缺席审判,否则等同于剥

〔19〕参见《刑事诉讼法》第301条第2款。

〔20〕施鹏鹏:《缺席审判程序的进步与局限——以境外追逃追赃为视角》,载《法学杂志》2019年第6期。

〔21〕前引〔20〕,施鹏鹏文。

夺被告人出庭权。比如意大利《刑事诉讼法》第 487 条规定：法官只有在被告人未出席庭审，且不具备“被告人尚未实际知晓庭审之事并且该事实不应归咎于被告人过错”和“被告人或辩护人出庭受阻”两种条件时，法庭才能对被告人进行缺席审判，否则该审判无效。^{〔22〕}

如果我国缺席审判程序在司法实践中不区分被告人在境外的主客观原因，那么有可能侵害非故意在境外被告人的出庭权。这样的缺席审判未能为被告人提供最低限度的权利保障从而缺乏正当性，也难以获得国外司法机构的承认与协助。

2. 被告人知情权可能受到减损

因为司法制度相异和本国公权力境外失效等原因，涉外送达本身十分困难，加上本次《刑事诉讼法》关于缺席审判送达程序的规定过于笼统，可能导致实际送达中问题重重，甚至侵害被告人知情权。另外，《刑事诉讼法》仅规定了缺席审判期间的送达程序，而对审查起诉阶段的告知和讯问程序尚未提及，这个阶段的犯罪嫌疑人、被告人的知情权没有法律保障，很容易受到威胁。

值得注意的是，缺席审判程序的“前身”是违法所得没收程序，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》第 11 条规定，人民法院可以在违法所得没收程序中采用公告送达；另外，在一些涉外案件中，当被告人所在地法律允许或被告人主动提出时，法院也会采用公告送达。因此法院在处理缺席审判的涉外送达程序时，如果被告人在境外下落不明，法院可能会更为方便地依照司法实践习惯，沿用以往没收程序中的公告送达。这一想法也得到了许多学者的支持，例如，有学者认为无法送达的情况在实践中客观存在，因此可以考虑将公告送达作为解决不能送达的方法之一，避免缺席审判程序的规定因送达不能而沦为一纸空文；^{〔23〕}也有学者支持用公告送达的方式保证被送达人及时收到司法文书。^{〔24〕}但我们认为，在缺席审判程序中适用公告送达不仅不符合刑事诉讼法理，还会威胁被告人的知情权。因为送达的本质是产生推定知晓效力，公告送达是一个主权国家的司法行为，根据属地原则，公告送达所产生推定知晓效力的边界止于本国领土，因此不能期望通过对境外被告人的公告送达，产生推定知晓的效力。如果此时法庭执意依据公告送达进行缺席审判，无疑会严重侵害被告人知情权。

3. 被告人辩护权难以有效行使

辩护权是被告人最重要的诉讼权利，因为诉讼的本质是公权力介入纠纷并公正地解决。公正，永远是刑事诉讼最根本的追求目标；辩论，则是保障公正的最佳手段。在辩论中，控辩双方直接对抗，充分陈述自己的理由并反驳对方的主张，这不仅

〔22〕参见《意大利刑事诉讼法典》，黄风译，中国政法大学出版社 1994 年版，第 174 页。

〔23〕甄贞、杨静：《缺席审判程序解读、适用预期及完善建议》，载《法学杂志》2019 年第 4 期。

〔24〕前引〔5〕，袁义康文。

符合正当程序,也利于发现案件真相。只有控辩双方在法庭上通过辩论提出的证据资料,才能作为法官断案的依据,才能使法官“兼听则明”,作出正确裁判。

缺席审判程序中,被告人难以行使自行辩护权,无法亲自在法庭上口头辩护,远在境外的被告人只能指望辩护人出庭代为辩护。一般情况下缺席被告人与辩护人会见都难以实现,更遑论细致详细地交流案件事实,共商辩护策略。此时被告人所获得的辩护质量实际上大打折扣,难以对抗掌握公权力的控诉机关,可能导致“控辩失衡”。

另外,缺席审判程序限制了被告人对质权,让有效辩护更加难以实现。因为刑事案件的审理过程是澄清事实与保护人权的有机统一,实现这种统一的最佳方式就是保证被告人充分行使对质权。对质权包括询问权和在场权两个子项权利,二者的共同目的都是让被告人通过自己言语或目光对证人施加影响,以形成证人证言这一重要证据。其中对控方证人的询问,更是被告人反抗控诉机关,为自己辩护的重要“武器”。因为控方证人通常在庭审前由控诉机关单独询问,所提交的证词对被告人非常不利,此时若将其交由被告人当场询问,能够极大提升证人证言的真实性和客观性。再联系到隐蔽性极强,过度依赖证人证言的贪污贿赂案件,可以说限制被告人行使对质权,就等于剥夺了其“反抗武器”,失去武器的被告人面对“火力”强大的控诉机关,更难有效行使辩护权。

4. 被告人上诉权与近亲属冲突

现代刑事诉讼中,审判仅针对被告人,因此上诉权由被告人独立享有,其委托的辩护人在被告人授权之下也可提出上诉。缺席审判同样仅针对被告人,因此世界各国刑事诉讼法都仅赋予缺席审判中被告人上诉权。例如,在美国,缺席审判仅适用于轻罪案件且需要被告人同意,因此上诉的主体与普通程序并无差异;在俄罗斯,缺席审判适用于所有案件,被告人的上诉权也与普通程序一致;在英国、德国、日本等国家同样未对缺席审判的上诉主体作专门规定。^{〔25〕}

但笔者认为,缺席审判程序中被告人身处国外不便于行使上诉权,又因为被告人近亲属与被告人接触较为密切,对被告人的具体情况甚至案件事实可能了解甚多,而且会坚持维护被告人的利益,为了充分保障被告人上诉权,缺席审判程序扩大了上诉主体,赋予被告人近亲属独立上诉权。这项规定极具中国特色,但两个独立的上诉权存在冲突的可能性。比如在司法实践中,当被告人尚未明确表达是否上诉,或者明确表达接受判决拒绝上诉时,其近亲属能否提出上诉?如果可以,明显违背被告人意愿,将被告人再次置于审判旋涡,被动地接受法庭和社会公众的审判,这对其生活和精神都会产生一定的影响,也不利于提高诉讼效率,浪费司法资源。

〔25〕杨帆:《刑事缺席审判制度的比较法考察——以适用范围与权利保障为切入点》,载《政治与法律》2019年第7期。

此外, 上诉不是简单地向法院提请, 背后可能隐藏着收集新的关键证据, 撰写新的辩护意见, 以及委托新的辩护律师等上诉准备活动, 如果被告人在忙于准备有利自己的上诉材料时, 其近亲属在没有与被告沟通, 也没有充分准备的情况下就向法院提请上诉, 显然是对被告人上诉权的一种侵害。

5. 被告人财产权救济保障不足

在缺席审判程序中, 被告人享有财产权救济这一实体性权利, 但细观法条论述, 我们发现财产权救济存在漏洞。缺席审判程序主要围绕“人的问题”展开, 但其背后是财产处理问题, 裁判的公正与否直接关系到财产处置的正当性。涉及被告人财产权的相关法条包括《刑事诉讼法》第 292 条规定的“……人民法院应当开庭审理, 依法作出判决, 并对违法所得及其他涉案财产作出处理”和第 295 条规定的“……依照生效判决、裁定对罪犯的财产进行的处理确有错误的, 应当予以返还、赔偿”。这两个法条对需要处理的财产的表述不同, 前者是“违法所得及其他涉案财产”, 后者是“罪犯的财产”。从字面理解, “违法所得及其他涉案财产”的范围大于“罪犯的财产”。即是说, 如果被告人到案后行使异议权, 法庭应当重新审理, 此时若发现之前的生效判决确有错误, 也只返还、赔偿“罪犯的财产”, 而“其他涉案财产”部分如何进行救济, 法条并未规定, 这直接威胁到被告人财产权。

此外, 在处理财产问题上, 缺席审判很有可能参见其“前身”——违法所得没收程序的做法, 而该程序在司法实践中存在着巨大的风险, 例如, 重庆反黑时期所采用的违法所得没收程序就存在不少问题, 导致被没收的违法所得被损坏、遗失, 甚至挪用、截留。^[26]最终导致纠正错判时的财产回转执行困难重重, 也严重损害了司法机关的公正形象。

四、缺席审判程序被告人权利保障的规范阐释

缺席审判程序存在“天然缺陷”, 在被告人未到庭的情况下径行审判会给被告人合法权益带来风险, 但如果在权利保障的路径设计上加以重视, 仍然能使缺席审判符合实体正义和程序正义的要求。为了使效果最大化, 跟缺席被告人有关的主要环节都需严格执行权利保障措施, 应当在启动条件、送达程序、有效辩护和救济范围上进行探索, 结合最新的技术手段与司法实践, 确保缺席被告人的权利得到保障。

(一) 程序启动: 仅对潜逃境外的被告人

缺席审判程序正当启动的前提之一是被告人主动放弃出庭权, 当在境外的被告人下落不明或客观滞留时, 法庭无法判断其是否主动放弃出庭权, 也就不能启动缺席审判程序。但在司法实践中, 要想直接证明被告人主动放弃出庭权难度极大, 只能先

[26] 邓立军:《违法所得特别没收程序的潜在风险与控制》, 载《法学评论》2015 年第 1 期。

将其行为认定为潜逃，之后才可以推定被告人主动放弃出庭权。

虽然潜逃行为的字面意思是“偷偷地逃走”，暗示被告人不希望被司法机关找到，但认定潜逃行为仍需确定被告人可用于送达相关文书的位置，否则应将其状态认定为下落不明，根据上文论述，针对下落不明者不宜启动缺席审判程序。这也是欧洲的通行做法，例如，欧盟 2016 年发布的《关于强化无罪推定的某些方面和强化刑事程序中参加审判权利的指针》，为缺席审判程序规定的最重要条件之一是：被调查人或被告人适时地知晓相关诉讼的存在以及不出庭的后果。此处“知晓”指实际知晓，应当将查无下落的外逃人员排除在缺席审判程序的适用范围之外。^[27]

在确定被告人可用于送达相关文书的位置之后，可将潜逃行为细分为三种行为类型：“躲避型”潜逃、“应对型”潜逃和“放任型”潜逃。第一种行为是“躲避型”潜逃，即被告人逃往境外后仍不希望被找到，并通过伪造身份、隐瞒行踪等手段躲避有关机构的追查。此时一定要注意识别“躲避型”潜逃和下落不明，区分二者的关键在于能否完成一次送达。如果我国司法机关掌握了被告人住址并对其进行一次送达，此时被告人已经明知自己将被追究刑事责任，再更换住址逃避审判，就是典型的“躲避型”潜逃；如果我国司法机关一直未能摸清被告人住址，一次送达都不能完成，那么被告人属于下落不明，不能对其启动缺席审判程序。第二种行为是“应对型”潜逃，即被告人逃往境外后不再积极躲藏，而是通过其他手段正面应对庭审，比如自选辩护人，接受相关文书的送达后积极回复辩护词等。第三种行为是“放任型”潜逃，即被告人拒绝送达或接受相关文书的送达后置之不理，对所涉案件采取不闻不问的态度。如果被告人拒绝送达，可以采用录像等手段留置送达，必要时也可以邀请当地司法机关工作人员前往见证，以便后续向其证明被告人实际知晓自己已被起诉。

总之，对拥有上述三种行为类型的潜逃被告人启动缺席审判程序的关键在于证明被告人已经知晓境内司法机构正在开展针对他/她的刑事诉讼活动，若此时被告人仍不返回境内接受审判，那么法庭可以推定其自愿放弃出庭权，从而正常启动缺席审判程序。至于下落不明和滞留境外的被告人，则不宜缺席审判。

（二）有效辩护：双重权利保障的逻辑基础

缺席审判程序中被告人不到庭，面对强大的国家机关追诉却无法亲自行使辩护权，这是对刑事诉讼“公正价值”的严重背离。为了减轻该程序对“公正价值”的损害，我们在制度设计上必须充分保障当事人获得有效辩护，因为有效辩护权是一项宪法性权利，^[28]是整个司法公正体系中的主要内容和支柱之一，^[29]也是刑事司法中保障

[27] 黄风：《对外逃人员缺席审判需注意的法律问题》，载《法治研究》2018年第4期。

[28] See Cf. *Powell v. Alabama*. 287 U. S. 45, 73 (1932).

[29] 祁建建：《论有效辩护权》，中国政法大学出版社2018年版，第4页。

犯罪嫌疑人、被告人程序性和实体性权利的基础。^{〔30〕}因此,《刑事诉讼法》第 293 条专门规定,缺席审判程序中,被告人及其近亲属都有权委托辩护人,没有委托的,法院应当通知法律援助机构为被告人指派辩护律师。该条款从法律层面上保障了被告人的辩护权,但要使缺席被告人获得真正意义上的“有效辩护”,以保障其程序性权利和实体性权利,司法实践中仍需要解决一些问题。

首先需要明确我国缺席审判程序中“有效辩护”的具体含义。广义上的有效辩护主要体现在联合国《公民权利和政治权利国际公约》第 14 条,即“被指控人有相当时间和便利准备他的辩护并与他自己选择的律师联络”。狭义上的有效辩护理念源于美国,法律术语是“effective assistance of counsel”,有学者将其翻译为“有效的律师协助”,^{〔31〕}这一理念传入中国后引发了学界的激烈讨论,但大体可以总结为两种观点:一是从辩护过程角度,认为尽职辩护就是有效辩护。二是从辩护结果角度,认为辩护质量是有效辩护的核心内容。这两种观点都有一定的道理,但我们认为,为了最大限度地弥补缺席被告人在抗衡“武装到牙齿”的公诉人时的天然劣势,狭义上的有效辩护应当同时从辩护过程(尽职辩护)和辩护结果(辩护质量)两个角度加以评判。具体到缺席审判程序中,真正的“有效辩护”应当包括广义上被告人的自行辩护权和狭义上“律师的有效协助”。如此一来才能更好地保障被告人程序性权利和实体性权利,具体规则如下:

一方面,保障广义上被告人的自行辩护权以及自主选择律师的权利。缺席审判程序中的被告人无法到庭发表意见,进行辩护,法院应当为其畅通发表意见的渠道。比如允许递交书面辩词,音频或视频辩词等;有条件的还可以尝试海外连线,通过微信、QQ 等即时通讯软件“网上开庭”,并做好证据固定。这些渠道和使用方法都应当在送达程序中明确。此外,被告人有权委托自己的辩护律师并自由地与其沟通,这是获得“律师的有效帮助”的前提。通常来说,被告人会更加信任自己选择的律师,后续沟通也能更加真诚,这与保障被告人自行辩护权同等重要。

另一方面,保障狭义上“律师的有效协助”。获得辩护人有效帮助的权利是所有权利中最具影响力的权利,它深刻影响着被告人行使其他权利的能力。一个专业的辩护人可以很大程度上协助被告人完整地行使诉讼权利,影响证据资料形成,并协助法庭查明案件事实,而案件事实是法庭定罪量刑的基础,直接影响被告人的生命权、自由权和财产权等实体性权利。因此,获得“律师的有效帮助”对保障被告人实体性权利至关重要,此外,我们认为缺席审判程序中的辩护人必须由律师担任。但这仅满足

〔30〕有效辩护本身即是正当程序的要求,保障辩护权才能更好地保障申请排除非法证据权、申请鉴定人出庭作证权、最后陈述权和对质权等其他程序性权利。此外,辩护的重要功能之一是查明事实,有效辩护才能有效查明事实,而案件事实是法庭定罪量刑的基础,直接影响被告人的生命、自由和财产等实体性权利。

〔31〕左卫民:《有效辩护还是有效果辩护?》,载《法学评论》2019 年第 1 期。

“律师的有效协助”的基础，实践中还应对辩护律师的任职资格、数量以及辩护活动加以细化规定。

首先要规范辩护律师任职资格，即缺席审判案件的代理律师必须熟悉刑事辩护业务。一般而言，市场会帮助被告人及其近亲属做出选择，但政府财政支持的法律援助律师，在辩护质量上可能不尽如人意。考虑到此类案件一般为重大案件，为了保障缺席被告人获得真正的“有效辩护”，缺席审判程序的法律援助规则可以参考死刑案件的要求。^[32]其次要保障辩护律师数量在两人以上。最后无论辩护律师如何资深，辩护团队如何庞大，最终让缺席被告人获得高质量“有效辩护”的还是取决于辩护律师的辩护活动。具体的辩护活动包括会见、阅卷、沟通和辩护。由于被告人缺席，因此需要通过强化辩护律师的诉讼权利来弥补，最重要的即是保障辩护律师的辩护活动具有充分的独立性（除上诉应受到被告人及其近亲属的限制），把辩护律师在缺席审判中的角色，拟制为能够行使被告人部分诉讼权利的“全权代理人”，以符合权责统一的要求。总之，缺席审判程序需要保障被告人的自行辩护权和获得“律师的有效协助”的权利，再严格履行其中的细节规定，如此才能称作一次真正的“有效辩护”。这可以在保障缺席被告人的程序性和实体性权利，以及说服国外司法机关承认我国司法判决等方面都做好最佳铺垫。

（三）程序权利：充分保障被告人知情权和上诉权的行使

成功送达传票和起诉书副本等相关文书是法院决定缺席审判的关键，也是后续审判活动的重要环节，因此法院要穷尽一切方法进行送达，确保被告人实际知情。同样，在审判之前的审查起诉阶段，检察院也应尽量落实告知和讯问程序，全力保障被告人知情权。

《刑事诉讼法》第34条第2款规定：“人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。”虽然可能适用缺席审判程序的犯罪嫌疑人此时不在案，但检察院仍应尽量履行此告知程序，不仅要告知在境外的犯罪嫌疑人有权委托辩护人，还需要告知其近亲属可以代为委托辩护人，以期间接通知犯罪嫌疑人。另外《刑事诉讼法》第173条规定：“人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人。”此时犯罪嫌疑人不在案，检察院应尽可能地利用即时通讯技术远程讯问被告人，也同样需要询问犯罪嫌疑人的近亲属。检察院在讯问和询问时，还需要听取犯罪嫌疑人的辩护律师或值班律师的意见，^[33]因为受执法观念、人力资源和当事人心理等因素影响，检察机关往往很难全面收集证据，此时听取律师的意见不仅

[32] 根据最高人民法院、司法部印发的《关于充分保障律师依法履行辩护职责确保死刑案件办理质量的若干规定》的通知，对死刑案件法律援助律师的任职要求是：“一、指派具有刑事案件出庭辩护经验的律师；二、被指定担任死刑案件辩护人的律师，不得将案件转由律师助理办理。”

[33] 《关于开展法律援助值班律师工作的意见》第2条明确指出值班律师不提供出庭辩护服务，犯罪嫌疑人及其近亲属在听取值班律师意见时检察院应当提醒这点，以便他们进行价值权衡。

有利于保障犯罪嫌疑人的合法权利,还能促进检察工作,从法律角度更加客观、全面地认定案件事实,公正处理案件。

在法庭决定适用缺席审判程序后,要及时启动对被告人的送达程序。根据上文论述,法庭将不得采用公告送达,除非被告人主动要求公告送达,因为此时可以推定被告人能够对公告送达内容实际知晓,也就无损其知情权。

及时送达是保障被告人知情权最重要的方式,在对知晓住址的被告人具体送达时,传票和起诉书副本等文书要明确告知被告人的各种诉讼权利,开庭的时间、地点、主审法官、控方检察官、法院联系电话、电子邮箱,以及放弃出庭的后果和救济程序。在送达方式上,能直接送达本人的送达本人,还需尽量采取让被告人亲自接收的方式,以保障其亲身感知诉讼进行的权利。^[34]法定的缺席审判送达方式有两种:通过有关国际条约规定的和外交途径提出的司法协助,^[35]但它们的实际效果却不尽相同,应当在充分比较两者利弊之后,选择最有利于保障被告人知情权的方式。

至于保障被告人上诉权的行使,如上文所述,缺席审判中两个上诉权产生冲突的原因在于地位平等,因此若想解决这个问题,必须先分析这两个表面平等的上诉权,并加以比较,确定出位阶更优的上诉权,然后通过司法解释明确它们的行使顺位。一方面是被告人的上诉权。这是缺席审判程序赋予被告人最重要的救济权利之一,体现着程序正义的基本思想,也反映出被告人寻求二审法院予以救济的主体意志。甚至从某种意义上说,上诉权实质上是辩护权的继续和强化。^[36]因为被告人行使辩护权的主要目的是充分陈述自己的意见以影响判决,若一审法院未采纳,此时被告人可以通过上诉继续补充自己的辩护意见,从而增大影响判决的概率。而且此时控方的定罪意见和主要证据已经和盘托出,等于“招数尽交”,一审法庭业已给出事实证据的认定以及法律适用的决定,上诉期等于给了被告人一个“见招拆招”和理解消化一审法庭判决的时期,利于其提出更有针对性的辩护意见。因此,被告人的上诉权在这里可以理解为“延续的、强化版”的辩护权。如上文所述,辩护权是一项宪法性权利,那么上诉权也同样可以理解为被告人的宪法性权利。^[37]

另一方面是被告人近亲属的上诉权。在一般的刑事诉讼中,被告人近亲属没有独立的上诉权(除法定代理上诉外),而缺席审判程序赋予了被告人近亲属独立的上诉权,此时可以将该上诉权理解为法律的特别赋权,即代表被告人利益的近亲属代为行使被告人的部分权利。法定赋权固然不可剥夺,但也不能与宪法性权利相冲突。鉴于刑事诉讼主要保障被告人上诉权,理应优先考虑被告人意愿,被告人近亲属的上诉

[34] 吴沈括:《意大利刑事缺席审判制度可资借鉴》,载《检察日报》2015年10月29日第3版。

[35] 参见《刑事诉讼法》第292条规定,“人民法院应当通过有关国际条约规定的或者外交途径提出的司法协助方式”送达。

[36] 李明舜:《辩护律师应有独立的上诉权》,载《法学家》1991年第1期。

[37] 潘庸鲁、孙晔:《上诉权的现实和理想》,载《中国刑事法杂志》2011年第8期。

权应当受到限制。只有穷尽一切告知手段仍无法获知被告人意愿,或者被告人明确表示不会上诉,此时才能允许被告人近亲属代为上诉。

(四) 实体权利:完善财产救济机制

在整个缺席审判的权利保障路径设计中,指导思想一直呈现“重人轻物”的特点,即对犯罪嫌疑人、被告人的人身权利保障较多,而疏于保护其财产。但缺席审判是兼具处理罪犯人身问题和财产问题两大功能的特别程序,甚至如果基于缺席判决的引渡请求失败,处理财产问题将成为缺席审判的主要任务。另外,从司法公正的角度看,人身权与财产权同等重要,因此权利保障路径设计的指导思想应当向“人物并重”转变,重视并完善缺席审判财产救济机制。

值得注意的是,保障被告人财产权这一实体性权利的首要前提是保障被告人的程序性权利。因为实体性权利的保障以程序性权利的行使为前提,只有经过正当程序的审判才能作出公正无误的判决,而判决书直接影响被告人的实体性权利。

为了防止被告人因受到不公正的缺席审判而导致其财产权受损,需要切实完善财产救济机制。

首先,缺席审判最大的财产救济问题即是法条表述前后有别,由字面含义推论出的财产救济范围不同,因此存在财产救济漏洞。而完善这一漏洞的主要方式是将“罪犯的财产”进行扩大解释,等同于“违法所得”和“其他涉案财产”,如此便能对所有涉案财产进行救济。其次,缺席审判具有非终局性特点,因此被告人到案后行使异议权,要求重新审理的可能性较大。此时法庭不能只关注对“人”的审理部分,同样需要将涉案财产一并重新审理,而且审理财产的标准应当和“审人”标准一致,即达到“犯罪事实清楚,证据确实、充分”的证明标准之后,才能将涉案财产认定为扩大解释后的“罪犯的财产”。最后,在执行“罪犯的财产”时,为了避免出现前文所述的损害、遗失、挪用和截留等情况,也为了方便实际执行和日后可能的回转执行,可以建立货币化标准,即量化,货币化“违法所得及其他涉案财产”,毕竟这些财物的属性不会因其处于犯罪领域而改变。^[38]要实现这个过程,最重要的是建立第三方机构评估体系,从而获得合理的货币价值量,再按照这个价值量进行判处,万一生效判决、裁定对财产的处理确有错误,也应依据这个价值量予以返还、赔偿。

结 语

新时代背景下提出了新的时代任务,建立具有中国特色的刑事缺席审判程序是对加强反腐追逃工作的回应,也是司法审理模式的一种创新。诚然,缺席审判程序设置了较为严格的适用条件,在程序上保障了当事人的知情权、辩护权、上诉权和涉及

[38]前引[26],邓立军文。

人身部分的异议权，在实体上也规定了当事人的财产权救济机制。但当我们全面地、整体地审视该程序，会发现缺席审判程序仍有可能侵害当事人的合法性权利。首先，不考量主观原因的缺席审判可能误伤非故意在境外的被告人；其次，未明确禁止公告送达可能威胁被告人的知情权；再次，被告人缺席可能无法实现有效辩护，事后行使上诉权也可能与近亲属的独立上诉权发生冲突；最后，法条前后表述相异的问题也可能侵害被告人的财产权利。

为完善缺席审判制度，保障被告人程序性和实体性权利，我们应当在现实国情与有限司法资源的基础上，形成具体的细化措施，例如，仅对潜逃被告人缺席审判；在辩护时确保被告人能获得“有效辩护”；在程序上保证被告人实际知情并规定好上诉时的权利行使顺位；在实体上注重保护被告人的财产权利。这样才能在惩治潜逃的腐败分子时，全面保障被告人的合法权利，维护司法公正，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

Abstract: The Criminal Procedure Law, amended in 2018, creates the criminal trial in absents. Its main purpose is to crack down on corrupt elements and improve the mechanism of capital recovery. As a newly created system, the legislative process of absentee trial proceedings has undergone intense debate and has raised questions about whether the procedure violates the principle of due process. In this regard, the criminal trial in absentia sets strict application and guarantees the rights of the accused both in procedural law and substantive law. However, relevant regulations are general, and the first implementation has no prior experience for reference. The trial procedure in absentia may still infringe on the rights of the accused when it is specifically applied, such as accidentally injuring the accused in a non-malicious manner and derogating from the defendant's right to know, right to defense, right to appeal and right to have property relief. In order to correct these shortcomings, we should clarify that only the accused who have fled abroad is subject to the trial in absentia, ensuring that the accused obtains the "effective defense", procedurally guaranteeing the defendant's right to know and clarifying the right to appeal. The mechanism of property relief should be effectively guaranteed in the procedural and substantive law in hopes to use the trial procedure in absentia to both punish the crime and protect the human rights of the accused.

Keywords: criminal trial in absentia; due process; effective defense; substantive rights; procedural right

（责任编辑：褚 宁）